

1500225-69.2022.8.26.0617
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS
Comarca: Jacareí
Foro: Foro de Jacareí
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/07/2022
... probatória.

Meros indícios da prática de tráfico de entorpecentes não são suficientes para lastrear um decreto condenatório:

"Tóxico - Tráfico - indícios e presunções - simples suspeita que não pode gerar condenação - Prova que deve ser cumpridamente feita pelo órgão acusador - Desclassificação para o delito de uso próprio - Recurso Provido". "...Não se deve, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jacareí
Foro de Jacareí
1ª Vara Criminal
Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500225-69.2022.8.26.0617 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500225-69.2022.8.26.0617
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2038338/2022 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 22928982 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 234/22/515 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2038338 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 234/22/515 - DISE- DEL.SEC.JACAREI
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FABIO FERNANDES DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1.FABIO FERNANDES DA SILVA e EDUARDO BARBOZA qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque, no dia 10 de Fevereiro de 2022, por volta das 01h40min, na Avenida José Teodoro De Siqueira, 1131, Jardim Yolanda, nesta cidade e comarca de Jacareí, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar, traziam consigo, para fins de tráfico, 23 porções e um pedaço de substância macerada (Fabio) e 15 porções de maconha (Eduardo).

A denúncia foi oferecida no dia 08 de março de 2022 (fls. 176/178).

Após a apresentação das defesas preliminares (fls. 198/201 e 208/210) a denúncia foi recebida no dia 14 de novembro de 2019 (fls. 229/233).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas. Ao final, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público postulou a procedência da ação penal e a condenação dos réus como incurso no artigo 33, da Lei de Drogas.

A Douta Defesa do réu Fabio pugnou pela absolvição dos réus acenando pela nulidade da prova produzida decorrente da prisão em flagrante dos acusados. Subsidiariamente requereu a desclassificação da imputação inicial para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. Estabelecida a condenação por tráfico de drogas requereu a fixação da pena no patamar mínimo, com a aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, facultando, ainda, a possibilidade de recurso em liberdade.

No mesmo sentido a manifestação final da Douta Defesa do corréu Eduardo.

É o relatório.

Fundamento e decido.

2.A ação penal é improcedente.

Com efeito, a materialidade delitiva estaria comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01 e ss.), Boletim de Ocorrência (fls. 02/06), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 44/45), bem como pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico que constatou tratar-se, efetivamente, de substâncias entorpecentes.

O réu FABIO FERNANDES DA SILVA, interrogado durante a fase policial, negou o crime, aduzindo que na data dos fatos estava na adega, no bairro Pq. Santo Antônio, Rua dos Crisântemos, defronte ao número 647, divertindo-se com seu amigo Eduardo, que também está separado da esposa. Como estava ficando bêbado foi buscar um "pó" a pé com Eduardo. Acontece que ao chegar na "biqueira" havia uma fila para comprar droga. Estava aguardando sua vez quando algumas pessoas começaram a correr. Uma menina gritou "corre, corre, vamos pro meu apartamento que lá é de boa". Não correu, apenas começou a andar para o bloco F, e entrou no referido apartamento. Não conhece a menina, não sabe nem o nome dela, a qual se encontrava lá na roda de pessoas tomando um copão de bebida. A polícia entrou no apartamento e passou a revistar o local, rumando para um dos quartos. De lá voltaram com uma sacola contendo droga. Perguntaram à garota de quem era a sacola, mas ela negou qualquer relação com as drogas. Negou veementemente estar na posse de qualquer porção de drogas quando foi abordado. Possuía apenas a quantia de R\$2,00 em seu bolso, pois os outros R\$10,00 já tinha dado para comprar droga para os menores que traficam no local. Em juízo, ao ser interrogado, o réu voltou a negar o crime, apresentando o mesmo relato. Quando a polícia apareceu houve uma correria. Maria Eduarda permitiu que entrassem na casa dela. A porta estava trancada e adolescente abriu para os policiais. Eduardo não ingressou no apartamento e foi colocado no local pelos policiais. Não tem qualquer relação com as drogas apreendidas, que foram forjadas pelos policiais que atuaram nesta ocorrência. Não tem conhecimento do dinheiro apreendido. Não conhecia os policiais que atuaram nesta ocorrência. É usuário eventual de drogas. Atualmente tem 36 anos de idade. Reside na cidade de Jacareí. Nunca foi preso ou processado criminalmente. É amasiado e tem dois enteados.

Trabalha como motoboy.

O corréu EDUARDO BARBOZA, interrogado em solo policial, também negou o crime, apresentando basicamente o mesmo relato de Fabio, de que estariam na adega e foram na biqueira comprar cocaína quando a polícia chegou e geral saiu correndo. Não correu e nem foi abordado no apartamento. Somente após a abordagem foi conduzido para o interior do referido imóvel. Não estava na posse de qualquer porção de drogas e também não é traficante. Em juízo, ao ser interrogado, negou novamente a imputação e apresentou o mesmo relato, aduzindo ser usuário de drogas. Questionou a conduta dos policiais que atuaram na ocorrência, afirmando ser pai de família. Os policiais queriam que declinassem os nomes dos "moleques" responsáveis pelo tráfico de drogas. Declarou que negou desde o primeiro momento qualquer envolvimento no crime. Queria apenas comprar cocaína para o seu próprio consumo. Atualmente tem 31 anos de idade. Reside em Jacareí. Já foi preso e processado por crime de roubo. Tem duas filhas. Estava trabalhando como motofrete e motoboy antes de ser preso. Sempre trabalhou regularmente após ser colocado em liberdade.

A testemunha UBIRATAN DOS SANTOS OLIVEIRA, policial militar, qualificado nos autos, declarou em solo policial que na data dos fatos, em patrulhamento de força tática foram até o condomínio Santa Isabel, tendo em vista que lá é local conhecido de ponto de venda de drogas. Quando adentraram ao condomínio, uma roda de pessoas empreendeu fuga. Dentre eles, dois indivíduos (um de blusa branca e outro de camiseta cinza com detalhes pretos) segurando sacolas foram sentido bloco F. Os ocupantes da viatura desembarcaram e iniciaram perseguição a pé, pelo interior do bloco F. No segundo andar, foram avistados os dois indivíduos adentrando ao apartamento 24. A equipe logrou abordar os implicados (Fabio e Eduardo). Com Fabio localizaram uma sacola verde com 23 porções e um grande pedaço de substância macerada, além de R\$65,00 trocados, além de um celular da cor preta. Com Eduardo, um saco preto contendo 15 porções de substância aparentando ser maconha e um aparelho de celular branco. Informalmente, após advertido dos direitos constitucionais, confessaram a prática de tráfico de drogas no local. Na residência estava a menor, Maria Eduarda Alves França, quem autorizou a entrada no imóvel que foi vistoriado e nada de ilícito localizado. Sua mãe, Sra. Roseli, não estava no apartamento, sendo necessário fazer contato e solicitando que comparecesse ao plantão policial. Em juízo, apresentou basicamente o mesmo relato, aduzindo que no condomínio palco dos fatos há inúmeras denúncias noticiando intenso tráfico de drogas. Os réus não residiam no apartamento onde foram abordados, onde residia uma adolescente que ao ser questionada disse que estava sozinha no local, pois a sua genitora não se encontrava. Entraram no imóvel pelo fato de que os réus correram para o interior. Tiveram contato com a adolescente apenas após ingressarem no local. A porta do apartamento não estava trancada. Nenhum outro indivíduo foi abordado ou preso no local.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar JULIANO JOSE DOS SANTOS, que participou da prisão dos réus. Já abordou o acusado Eduardo uma vez antes dos fatos. Os dois acusados não residem no condomínio palco dos fatos. Quando apareceu a viatura policial todos dispersaram.

A adolescente MARIA EDUARDA ALVES FRANÇA declarou em solo policial ser moradora do imóvel palco da diligência policial. No dia dos fatos estava subindo para a sua residência quando dois indivíduos subiram correndo e entraram em seu apartamento, trancando a porta. De imediato bateram na sua porta pedindo para abrir. Era a polícia militar. Quando abriu a porta os policiais disseram que a casa caiu. Um dos indivíduos, o mais fortinho, estava na sala e o outro, magrelo tatuado, estava escondido no quarto. Com o magrelo os policiais encontraram drogas e todos foram conduzidos ao Distrito Policial. Acionou a sua genitora para comparecer à Delegacia de Polícia.

Pois bem.

De rigor o reconhecimento da ilegalidade da prova produzida, especialmente o ingresso dos policiais na residência onde se encontrava a adolescente Maria Eduarda Alves França, que culminou com a apreensão das drogas, na esteira da jurisprudência sólida e recente do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Aliás, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que em caso absolutamente similar ao julgado nesta oportunidade que o avistamento de um indivíduo correndo para o interior de uma residência não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que, na residência em questão, estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não. E foi exatamente isso que aconteceu no caso em tela.

Afinal, a viatura policial ingressou no condomínio em testilha e todos os indivíduos que se encontravam em uma roda saíram correndo, incluindo os dois acusados, que ingressaram no apartamento onde mora a adolescente Maria Eduarda Alves França, a qual se encontrava sozinha no local, sem a presença de sua genitora.

Não há nos autos qualquer prova de consentimento da moradora (adolescente Maria Eduarda).

Aqui podemos até discutir uma possível validade de consentimento dado por uma adolescente. Mas temos relatos distintos apresentados pela adolescente na fase policial e pelos policiais na polícia e em juízo.

Note-se que a adolescente relatou que a porta da casa estava trancada e os policiais bateram. Os dois réus estavam dentro do imóvel. Ao abrir os milicianos afirmaram: "A casa caiu" e ingressaram no imóvel sem contar com a sua necessária anuência. Ou seja, a menor sequer teve a opção de permitir ou não o ingresso dos milicianos em sua casa.

Já os policiais afirmam que a porta da casa estava aberta e nela ingressaram sem ao menos pedir permissão ao morador/proprietário. Na polícia, ao revés, aduziram que a moradora permitiu o ingresso. Uma grande e grave contradição.

Portanto, seguindo o novo paradigma adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, a prova na espécie mostra-se ilícita. Nesse sentido o caso idêntico julgado recentemente:

"Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio. Tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção ativa. Invasão domiciliar efetuada por policiais militares sem autorização judicial, sem denúncia e sem diligências prévias. Ausência de consentimento escrito do morador. Fuga de indivíduo para o interior da residência, ao avistar a viatura policial. Ausência de justa causa. Nulidade das provas obtidas na busca e apreensão. Constrangimento ilegal evidenciado. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade

e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte. 3. O avistamento de um indivíduo correndo para o interior de uma residência não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que, na residência em questão, estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não. Necessária a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas (ex: "campana que ateste movimentação atípica na residência"). Precedentes. 4. Aliás, em recente decisão, a Colenda Sexta Turma deste Tribunal proclamou, nos autos do HC 598.051, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, Sessão de 02/03/2021 (...) que os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito. E apresentou as seguintes conclusões: a) Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. b) O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa, objetiva e concretamente, inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada. c) O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. d) A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo, e preservada tal prova enquanto durar o processo. e) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal dos agentes públicos que tenham realizado a diligência. 5. No caso concreto, embora o acórdão impugnado faça alusão à afirmação dos policiais responsáveis pela busca domiciliar de que o paciente teria autorizado a entrada na residência, evidencia que agiram sem mandado judicial e sem o amparo de denúncia ou de investigação prévias que os conduzissem a crer que naquele local havia tráfico de drogas. Suas suspeitas tiveram por base apenas o fato de que uma pessoa que estava na frente da casa correu para o seu interior assim que percebeu a aproximação da viatura policial. 6. Deve ser considerada inválida eventual autorização do morador da residência vistoriada, se essa autorização não foi concedida por escrito, na esteira da tese firmada no HC 598.051 (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), tanto mais quando a descrição dos procedimentos efetuada pelos policiais, em sede inquisitorial, se revela inverossímil, ao afirmarem que, após baterem à porta da residência, quando finalmente abriu, o paciente teria consentido na busca. 7. Reconhecida a ilegalidade da entrada da autoridade policial no domicílio do paciente sem prévia autorização judicial, a prova colhida na ocasião, bem como as derivadas, devem ser consideradas ilícitas. 8. Habeas corpus não conhecida. Ordem concedida de ofício para reconhecer a nulidade da prova colhida na busca domiciliar, bem como das provas derivadas, absolvendo o paciente das imputações de tráfico de drogas e corrupção ativa". (HC 686.489/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021 - grifo nosso)

Outrossim, acrescentando aos argumentos acima lançados verifico que nenhuma investigação preliminar foi desenvolvida pela polícia e tudo ocorreu dentro de mero patrulhamento rotineiro desenvolvido por policiais da Força Tática que atuam nesta cidade, em local onde haveria incidência de tráfico de drogas.

Uma pequena aglomeração e na sequência a corrida de indivíduos para locais diversos, dois deles para dentro de uma moradia do condomínio, não autorizava por si só a invasão ao imóvel, pois neste caso não houve qualquer consentimento do morador.

E para as próximas diligências fica a advertência aos policiais militares que procurem utilizar os seus respectivos telefones celulares enquanto não há a disponibilização de câmeras para todos os profissionais que atuam na rua, para filmagem do consentimento de moradores de uma determinada moradia para ingresso.

Frise-se novamente que a corrida dos suspeitos não caracteriza, segundo entendimento sedimentado pelo Tribunal Cidadão e Supremo Tribunal Federal, fundadas razões para o ingresso da polícia em uma moradia familiar. Portanto, anulada a prova produzida no interior do condomínio há dúvida sobre a efetiva prática delitiva por parte dos moradores, ensejando, neste passo, a absolvição por insuficiência probatória.

Meros indícios da prática de tráfico de entorpecentes não são suficientes para lastrear um decreto condenatório:

“Tóxico - Tráfico - indícios e presunções - simples suspeita que não pode gerar condenação - Prova que deve ser cumpridamente feita pelo órgão acusador - Desclassificação para o delito de uso próprio - Recurso Provido”. “...Não se deve, realmente, lastrear uma condenação pela prática de crime de tráfico de drogas com suporte apenas em indícios isolados, conjecturas, suposições ou meras suspeitas. O crime em apreço, equiparado, na qualidade, aos de natureza hediondo - Lei n. 8072, de 1980 - deve ser reprimido, com rigor, impondo-se penas severas àqueles que o cometem, para que se procure conter, na medida do possível, a disseminação das drogas, que se grassa a cada dia que passa, tomando-se, atualmente, num dos maiores flagelos da humanidade. Todavia, para que alguém seja responsabilizado criminalmente pelo seu cometimento e sofra a sanção respectiva, de forma justa e proporcional, é imprescindível que haja, ao menos, prova suficiente e sem isso a condenação poderá consubstanciar injustiça e a execução da pena uma arrematada violência. Por isso é que há julgados destacando sobre a necessidade de prova, com suficiência, para condenar alguém pela prática deste delito...” (JTJ 223/169, Rel. Cardoso Perpétuo, j. 11.11.98).

Ora, em matéria criminal, onde se busca a verdade real, não há como lastrear um decreto condenatório em provas frágeis e insuficientes.

“Não estando suficientemente demonstradas as provas da materialidade, autoria e o elemento subjetivo, simples indícios do ilícito não são suficientes para um Juízo de condenação” (TRF, 2ª Região - Ap. - Rel. Alberto Nogueira - RT 725/675).

Em Direito Penal a prova cabe a quem acusa e não pode ser dirigida a quem se diz inocente.

Brilhante a lição de Nicola Framarino Dei Malatesta: “O ordinário do homem é a inocência, por isso ela se presume e é ao acusador que cabe a obrigação da prova no juízo penal... Mas quando em geral se trata do ônus da prova em juízo penal, fala-se em obrigação de produzi-la como sustentação de uma dada afirmação. Ora, aberto o juízo penal, aí deverá sempre existir a imputação de crime e, por isso, um acusador e um acusado, bem como uma afirmação acusadora e uma eventual afirmação defensiva.

A estas duas asserções se refere o problema do ônus da prova, visando estabelecer qual das duas deve provar-se primeiro. Neste caso, não se poderá nunca dizer que a obrigação da prova incumbe ao juiz que deve pronunciar; o juiz, como tal, não afirma nada, deve julgar entre as várias afirmações e provas; é obrigação sua, como juiz, no momento da produção das provas, limitar-se a colher todas as provas que possam conduzir à verdade judicial, fim supremo de todo processo. Não é, portanto, errôneo, o falar de prova relativamente ao acusado e acusador. Voltando ao que dizíamos e concluindo, a inocência se presume. Por isso, no juízo penal, a obrigação da prova cabe à acusação" (A Lógica das Provas em Matéria Criminal, tradução Paolo Capitanio, ed. Bookseller, 1996, págs. 134 e 136).

3. Posto isso e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para o fim de ABSOLVER os réus FABIO FERNANDES DA SILVA e EDUARDO BAROZA do crime contra eles imputados na denúncia, com fundamento no artigo 386 VII do CPP.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Jacarei, 01 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA